

1500380-93.2022.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2032241/2022 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 22814381 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 249/22/917 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500380-93.2022.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500380-93.2022.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2032241/2022 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 22814381 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 249/22/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2032241 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2032241 - DEL.POL.GUARIBA, 249/22/917 -

DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON LUCAS BRAULIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

NELSON LUCAS BRAULIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 21h20, na Rodovia José Corona, 7, Jardim São Francisco, nesta cidade e comarca, transportava, para fins de tráfico, 11 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 10 quilogramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Exames toxicológicos a fls. 74/76.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia no dia 04 de maio de 2022 (fls. 156/158).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e, ao final, interrogado o réu.

Em debates, o representante do Ministério Público, pugnou pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delitiva. A defesa do acusado, por sua vez, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo diante do desconhecimento do réu acerca do transporte das substâncias ilícitas.

É o relatório.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame químico-toxicológico acostado a presença de substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.

O policiais militares Iranildo Monteiro e Adonias Barreiro Camilo, ouvidos em Juízo, disseram que no dia dos fatos abordaram o acusado em um veículo, oportunidade em que, em revista, encontraram as drogas no automóvel. Indagado no momento da abordagem, o acusado não explicou a origem dos entorpecentes. O cabo Monteiro informou que a caixa com os entorpecentes não estava lacrada.

O réu, em seu interrogatório, disse que combinou com terceira pessoa o transporte de mercadoria que desconhecia a origem.

Outrora, os milicianos afirmaram de forma uníssona na fase extrajudicial e em juízo as circunstâncias do flagrante, com circunstâncias que revelam nitidamente que o entorpecente era destinado à comercialização – ante o local do flagrante, a quantidade de entorpecente apreendido e a forma de acondicionamento – esta típica da realização da venda no varejo da droga, circunstância em que comumente o traficante esconde a droga nas proximidades do seu ponto de venda.

É sabido que para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceira pessoa, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF – AC 13.847/94 – Rel. Pingret de Carvalho – DJU 3, 3.8.94, p.8745). “Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Assim, quando o agente tinha em depósito a droga destinada à venda, o delito consumou-se e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Então, demonstrado quantum satis que o acusado trazia consigo a substância denominada maconha, com destino a terceiras pessoas, configurou-se a situação fática que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que os policiais apresentaram declarações harmônicas e coesas, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem, injustificadamente, incriminar o réu ou forjar o crime. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" .

Fosse frágil a prova, teriam as testemunhas divergido em pontos relevantes, sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nada a indicar em tal sentido, pelo contrário, há provas irrefutáveis do tráfico pelo réu exercido. Por fim, inexistindo dúvida quanto à autoria do fato, sua materialidade delitiva e tipicidade, não há como se acolher a pretendida absolvição reclamada pela defesa do réu, impondo-se a condenação de pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosagem da pena:

Considerando as circunstâncias judiciais, conforme dispõe o artigo 42, da Lei n.º 11.343/06 combinado com o artigo 59, do Código Penal, verifico que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida pertinente e necessária para a prevenção e repressão da prática criminosa em comento.

Com efeito, o artigo 42, da Lei n.º 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente sejam consideradas circunstâncias preponderantes sobre quaisquer outras previstas no artigo 59, do Código Penal, na primeira fase de dosimetria da pena. Assim, fixo a pena base em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias multa, em seu valor mínimo unitário;

Reconheço a agravante da reincidência, conforme certidão juntada aos autos (fls. 99/102), aumentando a pena em um sexto, elevando-a assim ao patamar de 07 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias multa. Sem atenuantes.

Ante a reincidência, incabível a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena delineada retro.

Ante o montante de pena, não há pensar-se em sursis ou em substituição por pena restritiva de direito.

Diante da quantidade da pena e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, possibilitada a progressão.

Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar (manter a ordem pública, evitando-se a difusão das drogas por meio do comércio, como vinha fazendo o acusado até então), não poderá apelar em liberdade.

No que se refere à nova roupagem da detração penal, com a publicação da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, entendo serem inconstitucionais o art. 1º e o § 2º do artigo 2º da mencionada lei, pelos motivos que passo a explicar, pois violadores de princípios caros a um Estado de Direito, quais sejam, os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.

O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais, que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou

cumulativamente. Na etapa judiciária, caberá ao juiz, diante da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as previstas pelo legislador, dosar a sua quantidade, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por restritiva de direitos, obedecendo-se as regras previstas no Código Penal. Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei das Execuções Penais. A nova lei, lamentavelmente, diga-se, talvez objetivando indecoroso desejo de esvaziar cadeias e presídios a qualquer custo, colocando em risco a população ordeira, reuniu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, contrariando o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Tal dispositivo estabelece o seguinte: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (observa-se que há regra específica para crimes hediondos, com relação ao tempo necessário para a progressão- Art. 2º, § 2º, da lei nº 8.072/90)" Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, por exemplo, o condenado à pena privativa de liberdade e que tenha respondido o processo preso terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que tenha respondido todo o processo em liberdade, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF).

Tal situação afronta, ainda, a razoabilidade, pois facilitar-se-ia a progressão de indivíduos que responderam ao processo encarcerados, em detrimento dos que responderam em liberdade, sendo que aqueles, via de regra, representam um maior risco para a sociedade.

Por tais razões, entendo que a mencionada lei mostra-se inconstitucional por violar de forma flagrante as mencionadas disposições.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, condeno NELSON LUCAS BRAULIO, qualificado nos autos, à pena de 07 anos de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 700 dias multa, em seu valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos pelo montante de pena aplicado, bem como por entender não compatível a medida com a espécie de crime praticado e sua gravidade para a sociedade.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, observando se o caso da Lei nº 1060/50.

Quanto ao valor do dia-multa, cada qual será estabelecido em seu menor valor monetário, nos termos do art. 43, da Lei nº 11.343/06. Ademais, considerando o abalo à ordem pública que demonstra poder oferecer o condenado, e pelo fato de já

se encontrar recolhido em estabelecimento prisional em decorrência da prisão cautelar, não poderá apelar em liberdade, devendo ser mantida a custódia preventiva.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido.

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários em favor do patrono do acusado, no valor máximo previsto em tabela.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal), expedindo-se guia de execução e providenciando-se o necessário para a anotação da condenação no registro de antecedentes do réu.

P.I.C

Guariba, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA